

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 261/2563 พนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม  
นาย ว.

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 192 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา กลางวัน แต่ข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของผู้เสียหายในชั้นพิจารณากลับปรากฏว่า เป็นเวลากลางคืน เวลาตามที่ปรากฏในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับวันเวลาที่กล่าวใน ฟ้อง แต่เมื่อได้ความตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหาว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จ จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดว่า ผู้เสียหายกล่าวหาว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายในวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 23 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลากลางคืน จำเลยให้การรับว่าใน วันเกิดเหตุดังกล่าวจำเลยอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุ แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำชำเราผู้เสีย หาย และในชั้นพิจารณาจำเลยเบิกความแต่เพียงว่า ในวันดังกล่าวจำเลยจำไม่ได้ว่า อยู่ที่ไหน แสดงว่าจำเลยมิได้หลงต่อสู้ เมื่อข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาดังกล่าวมิใช่สาระ สำคัญ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจึงลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้ ตามข้อยกเว้นใน ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 276, 277, 285

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 285 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 10 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 40 ปี (ที่ถูก คำขออื่นให้ ยก)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่า เด็กหญิง ฐ. ผู้เสียหาย เป็นบุตรของจำเลยกับนาง อ. ขณะเกิดเหตุอายุ 12 ปีเศษ และพักอาศัยอยู่กับจำเลยและนาง อ. ที่บ้านเกิดเหตุ บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวมีทั้งหมด 4 ห้อง เป็นห้องนอน 3 ห้อง และห้องครัว ตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ ห้องหมายเลข 1 เป็นห้องนอนของจำเลย นาง อ. และผู้เสียหาย โดยมีผ้า màn กั้นระหว่างเตียงนอนของจำเลยและนาง อ. กับที่นอนของผู้เสียหาย วันที่ 4 มกราคม 2561 นาง อ. พาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยข้ากล่าวหาจำเลยเป็นคดีนี้ จำเลยให้การปฏิเสธตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหา ผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายตรวจสอบภายในพบบาดแผลฉีกขาดเก่าของเยื่อพรหมจารี แพทย์ผู้ตรวจลงความเห็นว่าจะผ่านการร่วมประเวณีหรือถูกกระทำชำเรา

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้แม้โจทก์จะมีผู้เสียหายซึ่งเป็น

ประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุเพียงปากเดียวมาเบิกความในเรื่องนี้ก็มีเหตุผลน่าเชื่อถือ เพราะการเบิกความของพยานปากนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมาไม่ได้มีพิรุธว่าจะมีการเลี่ยมสอนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใด ถ้าผู้เสียหายไม่ถูกจำเลยกระทำชำเราจริง ก็คงจะไม่กล้านำเหตุการณ์ที่น่าอัปยศมากลั่นแกล้งใส่ร้ายจำเลยซึ่งเป็นบิดาของตนให้ต้องรับโทษทางอาญา ซึ่งตามปกติแล้วผู้เสียหายต้องให้ความเคารพยำเกรงจำเลยเพราะเป็นผู้เลี้ยงดูผู้เสียหาย เหตุที่ผู้เสียหายถูกจำเลยกระทำชำเราแล้วผู้เสียหายปิดบังไม่ยอมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครทราบก็ไม่ส่อพิรุธแต่อย่างใด เพราะขณะเกิดเหตุผู้เสียหายยังเยาว์วัยอายุเพียง 12 ปีเศษ ย่อมมีความคิดอ่านตามประสาของเด็ก จำเลยเป็นบิดาของผู้เสียหาย เมื่อจำเลยพูดขู่ไม่ให้ผู้เสียหายบอกใคร ถ้าบอกจำเลยจะฆ่าผู้เสียหายรวมถึงคนในครอบครัวของผู้เสียหาย ผู้เสียหายย่อมมีความเกรงกลัวจำเลยอยู่เป็นธรรมดา และผู้เสียหายรอจนกระทั่งจำเลยไม่อยู่ที่บ้านเกิดเหตุจึงกล้าเล่าเรื่องที่ตนถูกจำเลยกระทำชำเราให้นาง อ. ผู้เป็นมารดาทราบ ซึ่งนาง อ. ก็เบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ตนจริง แม้ผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายจะไม่พบตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่ตามผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผล ระบุว่าตรวจพบบาดแผลฉีกขาดเก่าของเยื่อพรหมจารี โดยนายแพทย์ จ. แพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า การตรวจพิสูจน์อวัยวะเพศหญิงที่ผ่านการร่วมประเวณีจะดูได้ที่เยื่อพรหมจารีมีการฉีกขาดหรือไม่ หากมีการร่วมประเวณีมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง จะพบร่องรอยการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีและมีเลือดติดอยู่ จากการตรวจภายในผู้เสียหายพบเยื่อพรหมจารีฉีกขาดเก่าแต่ไม่มีรอยเลือดติดอยู่ และพบสารคัดหลั่งเป็นมูกสีขาวอยู่ที่ปลายสุดของช่องคลอด เมื่อนำไปตรวจไม่พบตัวอสุจิ เนื่องจากคดีนี้เหตุเกิดวันที่ 1 มกราคม 2561 แพทย์ทำการตรวจร่างกายผู้เสียหายในวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 72 ชั่วโมง จึงทำให้ตรวจไม่พบ พยานมีความเห็นว่าผู้เสียหายน่าจะผ่านการร่วมประเวณีหรือถูกกระทำชำเรา และพยานยัง

ได้เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ก่อนที่พยานจะตรวจร่างกายผู้เสียหาย ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกจำเลยซึ่งเป็นบิดากระทำชำเรา ขณะนั้นมีเพียงผู้เสียหาย พยาน และเจ้าหน้าที่พยาบาล ส่วนมารดาของผู้เสียหายรออยู่นอกห้องตรวจ ดังนั้นคำเบิกความของนาง อ. และนายแพทย์ จ. จึงมีน้ำหนักสนับสนุนให้คำเบิกความของผู้เสียหายมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีและเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดานตามฟ้องจริง

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ระบุว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลากลางวัน จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของผู้เสียหายในชั้นพิพากษาลับปรากฎว่าเป็นเวลากลางคืน เวลาตามที่ปรากฎในทางพิพากษาจึงแตกต่างกับวันเวลาดังที่กล่าวในฟ้องนั้น เห็นว่า การที่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในทางพิพากษาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องเกี่ยวกับเวลากระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจึงไม่เป็นเหตุให้ต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง เว้นแต่จะปรากฎแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ จึงจะถือว่าข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ต้องยกฟ้อง ได้ความตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหาว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดว่า ผู้เสียหายกล่าวหาว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายครั้งที่สองในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 23 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลากลางคืน ซึ่งจำเลยให้การรับว่าในวันเกิดเหตุดังกล่าวจำเลยอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุ แต่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำชำเราผู้เสียหาย และในชั้นพิจารณาจำเลยเบิกความแต่เพียงว่า ในวันดังกล่าว จำเลยจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ใด แสดงว่าจำเลยมิได้หลงต่อสู้ กรณีมิใช่เรื่องที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ เมื่อข้อ

แตกต่างกันดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจึงลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่จำต้องวินิจฉัย พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

หนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 และมาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 285 และให้ใช้ความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ประกอบมาตรา 285 (เดิม) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ภัทรศักดิ์ วรรณแสง -ชัยรัตน์ ศีลาลัย-อำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล)

ศาลจังหวัดเดชอุดม - นายสุรศักดิ์ ชูผล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายธรรมนิธย์ ตันติยวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1710/2561

ต้น

หมายเหตุ